

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/1034

Acusados: Marco Aurélio Carvalho Côrtes
TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

Ementa: Administração irregular de carteira de valores mobiliários – exercício da atividade de administrador de carteira sem a prévia autorização da CVM.
Proibição temporária e Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1. Na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, por maioria, aplicar à **TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00**, pela atuação irregular na administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao disposto nos artigos 3º da Instrução CVM nº 306/99; 23 da Lei nº 6.385/76; e 16, inciso VI, alínea “b”, da Instrução CVM nº 434/2006; e
2. Na forma do inciso VII do art. 11 da Lei nº 6.385/76, por maioria, aplicar ao acusado **Marco Aurélio Carvalho Côrtes, a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de seis anos, para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários**, por ter agido irregularmente como administrador de carteira de valores mobiliários, infringindo, dessa forma, o disposto nos artigos 3º da Instrução CVM nº 306/99; 23 da Lei nº 6.385/76; e 16, inciso VI, alínea “b”, da Instrução CVM nº 434/2006; e

O Colegiado deliberou, por fim, comunicar o resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 27/2015 (fls. 183) para as providências que aquele órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria, e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/1034

Acusados: TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
Marco Aurélio Carvalho Côrtes

Assunto: Atuação irregular como administrador de carteira de valores mobiliários (infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999, ao art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e ao art. 16, inciso VI, alínea “b” da Instrução CVM nº 434, de 2006).

Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I – Do Objeto:

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), em face de TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (“**TDS AAI**”) e Marco Aurélio Carvalho Côrtes (“**Marco Aurélio**”), por atuarem de forma irregular como administrador de carteiras de valores mobiliários, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999¹, ao art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976², e ao art. 16, inciso VI, alínea “b” da Instrução CVM nº 434, de 2006³ (fls. 01/16).

II- Dos Fatos:

2. O processo originou-se de reclamação de M.A.C. e F.H.L.C. (“**Investidores**”) protocolada junto a CVM em 05/4/2011, na qual alegam, em suma, que (fls. 17/27 e anexos às fls. 28/120)⁴:

- a) Marco Aurélio era *“pessoa conhecida no Estado de Mato Grosso como ‘Assessor Financeiro’ com especialidade em renda variável (em especial bolsa de valores)”*, reconhecimento decorrente da promoção de cursos sobre o mercado de ações na Capital do Estado e no Interior;
- b) Ao conhecer os Investidores, em meados de 2009, Marco Aurélio sugeriu que abrissem contas na S. Corretora e que, ato contínuo, lhe repassassem suas senhas pessoais de acesso ao *home broker* para que operasse em nome deles;
- c) Como sugerido, forneceram a Marco Aurélio as senhas do *home broker* na S. Corretora, bem como transferiram recursos para as respectivas contas;

- d) Os Investidores não eram previamente consultados sobre as operações, atuando Marco Aurélio como gestor de carteiras;
- e) Foi acordado pagamento de R\$500,00 mensais por investidor, caso houvesse lucro superior a R\$1.000,00 no mesmo exercício, obrigação esta posteriormente rescindida em dezembro de 2009, sob alegação de acordo firmado com a S. Corretora para dispensa do pagamento;
- f) Os boletos possuíam como cedente a Ortiz Agente Autônomo de Investimentos Ltda. - TDS;
- g) Foram os Investidores aconselhados por Marco Aurélio a não acompanhar os extratos e correspondências pertinentes aos seus investimentos, enviados pela S. Corretora, sob o argumento de que não os entenderiam por ignorância técnica;
- h) Marco Aurélio lhes fornecia relatórios mensais que traduziam ganhos expressivos;
- i) Em janeiro de 2010, os ativos dos Investidores foram transferidos para outra corretora (X. Corretora), mantendo-se o mesmo *modus operandi*. À época, Marco Aurélio alegou que estaria tendo várias dificuldades junto à S. Corretora;
- j) A partir de telefonema de agente autônomo da X. Corretora, em maio de 2010, os Investidores tomaram ciência de que havia uma enorme diferença entre os valores informados pela corretora e aqueles informados por Marco Aurélio, tendo em seguida descoberto o histórico deste, cuja atuação já foi objeto de decisão administrativa da CVM;
- k) Diante disso, encerraram as operações de risco que possuíam junto à X. Corretora; e
- l) Marco Aurélio assumiu a responsabilidade pelos danos causados ao assinar duas notas promissórias em favor dos Investidores, que propuseram perante o Poder Judiciário execuções de títulos extrajudiciais visando à cobrança dos valores dispostos nas notas promissórias por ele emitidas e não pagas.

3. Salienta-se que a TDS AAI e Marco Aurélio não possuem, tampouco já possuíram, autorização desta CVM para a prestação de serviços de administração de carteiras. Além disso, Marco Aurélio e a TDS System Ltda., esta última sociedade da qual era controlador, foram condenados pela CVM justamente pela prestação de serviços de administração de carteira sem o devido registro junto a esta Autarquia (Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/10874, julgado em 28/4/2009)⁵.

4. Segundo informações extraídas do Sistema de Cadastro da CVM (fls.121/123), a partir de 14/5/2010, Marco Aurélio tornou-se único sócio agente autônomo da Ortiz Agente Autônomo de Investimentos Ltda., que funcionava no mesmo endereço da TDS AAI. Ademais, como se verifica dos documentos às fls. 39, 47, 50, 55, 68 e 76, alguns boletos pagos pelos investidores possuíam como cedente "Ortiz Agente Autônomo Investimentos Ltda. – TDS".

5. Marco Aurélio e a TDS AAI foram ainda citados por outros dois investidores, I.M.S. e D.C.F.A.P., que também apresentaram reclamação junto à CVM⁶ relacionada à administração irregular de carteira de valores mobiliários.

6. Nos termos do art.11, parágrafo único, inciso II, da Deliberação CVM nº538, de 2008⁷, Marco Aurélio e a TDS AAI foram instados a se manifestar acerca dos fatos⁸, porém, não obstante tenham os ofícios sido enviados para os endereços constantes da base de dados do SERPRO (fls. 149/150), foram os mesmos devolvidos pelos Correios⁹. Nova tentativa foi realizada¹⁰, desta vez para os endereços constantes do cadastro (cancelado) dos agentes autônomos de investimentos junto à CVM (fls. 121/122), também sem sucesso¹¹.

III – Da Acusação:

7. Diante destes fatos, a SIN concluiu que restou caracterizada a atuação irregular como administrador de carteira de valores mobiliários por parte de Marco Aurélio e da TDS AAI, por não serem credenciados pela CVM, e se reporta aos comandos do art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976¹² e dos artigos 2º e 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999¹³.

8. Mencionou, ainda, a decisão contida no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/4778, julgado em 17/10/2006, quando se estabeleceu os requisitos que configurariam a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários:

18. (...) é possível definir cada um dos elementos necessários à configuração da administração de carteira de valores mobiliários. Farei abaixo essa decomposição e mencionarei a prova ou fato que comprova o preenchimento desse elemento:

- (i) Gestão (...)*
- (ii) Gestão Profissional. Por gestão profissional, deve-se entender aquela que se faz de ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou parentesco (...)*
- (iii) Gestão de Recursos entregues ao administrador (...)*
- (iv) Com autorização para que este Compre ou Venda Títulos e Valores Mobiliários por conta do Investidor (...).*

9. No entendimento da SIN, a gestão de recursos estaria comprovada a partir de diversas mensagens eletrônicas trocadas entre Marco Aurélio e os Investidores, como se observa, por exemplo, das mensagens dos dias 26, 27 e 28/8/2009 (fls. 30/31 e 36/37):

*De: [M.A.C.]
Para: Marco Aurélio – TDS Investimentos*

acabei de mandar 80.000,00

*De: Marco Aurélio – TDS Investimentos
Para: [M.A.C.]*

blz.... vamos começar a trabalhar prepara-se para ganhar bastante dinheiro...

*De: [M.A.C.]
Para: Marco Aurélio – TDS Investimentos*

Olhei minha carteira e vi que vc já mexeu. Pode me indicar o que foi feito?

De: Marco Aurélio – TDS Investimentos

Para: [M.A.C.]

vendemos csna3 para recomprar mais abaixo e compramos valei32, para vender hoje na abertura, se abrir subindo um pouco... preciso esperar o mercado se definir (se volta a subir ou cai mesmo), para adotarmos o ponto certo de entrar com o dinheiro todo.

10. A Acusação reporta-se ainda à mensagem eletrônica enviada pelos Acusados a outro investidor, I.M.S., que igualmente protocolou reclamação junto a CVM, como comentado no item 7 acima:

Bom dia I...

Estamos vendidos em 42000 vale 5 (25,80) e 30000 petr4 (23,45).

Tivemos um prejuízo naquela operação R\$ 41.888,00. Depois disso, operamos menos, mas recuperamos 22.280,00. Tivemos que rolar as opções da serie para serie B24, que não nos deu nem lucro nem prejuízo.

Sendo assim, a posição está em R\$ 112.392,00, levando-se em consideração se recomprarmos as ações vale5 e petr4 no mesmo valor. Também compramos Valeb26 e Petrb24 para fazer a trava e ficar vendido nas opções. Hoje está caindo e está dando certo, portanto, vamos continuar torcendo para a queda. Quer dúvida, vc me avisa. Dia 29/1 estarei em Campo Grande

Atenciosamente,

Marco Aurélio

11. A SIN concluiu que as mensagens eletrônicas evidenciam o efetivo poder de decisão de que gozavam a TDS AAI e Marco Aurélio para a realização de investimentos com os recursos disponibilizados pelos seus clientes, utilizando-se dos *logins* e das senhas para uso do *home broker* da corretora fornecidos pelos mesmos, como comprovado às fls. 30 a 33.

12. Especificamente quanto ao caráter profissional da atividade de gestão, a SIN destacou a existência de provas aptas a demonstrar a prestação do serviço de administração de carteiras mediante remuneração e com habitualidade, a saber: (i) a própria afirmativa dos Investidores acerca do acordo de pagamento de R\$500,00 mensais por investidor, caso houvesse lucro superior a R\$1.000,00 no mesmo exercício; (ii) as mensagens eletrônicas trocadas entre os Investidores e Marco Aurélio, com o objetivo de combinar os pagamentos (fls. 45, 52 e 53); e (iii) a comprovação desses pagamentos por meio dos boletos bancários de fls. 39, 47, 50, 55, 57, 64, 68 e 76, emitidos em favor da Ortiz Agente de Investimentos Ltda. – TDS, detalhados na Tabela 1 do Termo de Acusação.

13. Nesse tocante, a SIN destacou que, consoante informação constante do Sistema de Cadastro da CVM (fl. 123), à época dos fatos, a Ortiz Agente Autônomo de Investimentos Ltda. tinha como único sócio agente autônomo o Sr. E.B.O., que também trabalhava na TDS AAI, segundo se infere da mensagem eletrônica de 19/2/2010, à fl. 79. Por sua vez, a partir de 14/5/2010, Marco Aurélio tornou-se o único sócio agente autônomo da Ortiz.

14. Ainda de acordo com a SIN, o caráter profissional dos serviços de administração de carteiras de valores mobiliários prestados pelos Acusados é

reforçado pelos relatórios mensais referentes ao desempenho das carteiras, enviados pela TDS AAI aos Investidores, conforme comprovam as mensagens eletrônicas às fls. 42/44 ("Fechamento Agosto"), 46/51 ("Fechamento Setembro"), 54/59 ("Fechamento Outubro") e 63/69 ("Fechamento Novembro"). Nessas mensagens, além de comentários gerais sobre o desempenho dos mercados e das estratégias adotadas, os Acusados enviavam aos investidores os boletos para pagamento de sua remuneração e planilha com as supostas operações realizadas e os ganhos obtidos durante o mês. Tais relatórios, que inicialmente eram enviados pelo próprio Marco Aurélio, passaram, a partir de janeiro de 2010, a ser enviados aos Investidores por outros funcionários da TDS AAI, entre eles o Sr. E.B.O., acima referido (fls. 79/87).

15. Quanto ao terceiro requisito necessário para a caracterização do exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de recursos entregues ao administrador), a SIN reporta-se às mensagens eletrônicas por meio das quais os Investidores forneceram aos Acusados o *login* e a senha de acesso às suas respectivas contas junto ao sistema de *home broker* da corretora (fls. 30/33), além das mensagens eletrônicas por meio das quais os Investidores confirmam o depósito de valores nessas contas, para serem geridos pelos Acusados (fls. 30/31 e 36/37)¹⁴.

16. Finalmente, quanto ao último requisito (autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários), a SIN novamente alude, entre outras, às mensagens eletrônicas referentes ao fornecimento do *login* e senha de acesso ao *home broker*, a indicar que existia uma autorização dada pelos Investidores para compra e venda de títulos e valores mobiliários.

17. Assim sendo, a SIN concluiu pela existência de elementos de prova suficientes a evidenciar o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários pela TDS AAI e por Marco Aurélio, sem que detivessem o prévio registro exigido pelo art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e pelo art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999. Adicionalmente, a SIN concluiu pela infração ao art. 16, inciso IV, "b", da Instrução CVM nº 434, de 2006, considerando que, à época dos fatos, os Acusados estavam registrados junto à CVM como agentes autônomos de investimento (fls. 121/122).

IV - Das responsabilidades:

18. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização da TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. e de Marco Aurélio Carvalho Côrtes, por infringência ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, no art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999, e no art. 16, inciso IV, "b", da Instrução CVM nº 434, de 2006.

V – Da manifestação da Procuradoria:

19. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, ambos da Deliberação CVM n.º 538/08¹⁵.

VI - Da Comunicação ao Ministério Público:

20. Em 13/3/2015, o Superintendente Geral da CVM encaminhou cópia do Termo de Acusação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, tendo em vista a existência de indícios de crime de ação penal pública (fls. 183).

VII - Das defesas:

21. Os Acusados, devidamente intimados, não apresentaram razões de defesa. Eles foram intimados a apresentar defesa por meio de Edital publicado no Diário Oficial da União em 07/5/2015 (fls. 203), após duas tentativas de intimação postal, sem sucesso¹⁶.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

¹ Art. 3º. A administração profissional de carteiras de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.

² Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

³ Art.16. É vedado ao agente autônomo de investimento:

(...)

IV – contratar com investidores a prestação de serviços de:

(...)

b) administração de carteira de títulos e valores mobiliários, salvo se o agente autônomo – pessoa natural, autorizado pela CVM também para exercer a atividade de administração de carteira, não estiver contratualmente vinculado, direta ou indiretamente, a entidades do sistema de distribuição de valores.

⁴ A Reclamação foi também analisada no âmbito de recurso ao Colegiado contra decisão proferida pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados em sede de Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos – MRP (Processo Administrativo CVM nº RJ2014/2113, Reunião do Colegiado de 18.11.2014).

⁵ Marco Aurélio e a TDS System Ltda. foram condenados à penalidade de multa no valor de R\$150 mil e R\$50mil, respectivamente.

⁶ Processos Administrativos CVM nº RJ2012/12208 e nº RJ2011/3888.

⁷ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

⁸ OFÍCIO CVM/SIN/GIA/Nº 612/2014 (fls. 145/146) e CVM/SIN/GIA/Nº 835/2014 (fls. 147/148) ambos em 28.03.2013

⁹ No caso de Marco Aurélio, por “mudança de endereço”, e no caso da TDS AAI, por “pessoa desconhecida”.

¹⁰ OFÍCIO CVM/SIN/GIA/Nº 2.259/2014 (fls. 153/154) e OFÍCIO CVM/SIN/GIA/Nº 2.260/2014 (fls. 155/156)

¹¹ Os Ofícios enviados na modalidade de Aviso de Recebimento retornaram pelo motivo de mudança de endereço (fls. 157/158).

¹² Art. 23 – O exercício profissional da administração de carteira de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da comissão.

§ 1º O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.

¹³ Art. 2º - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

Art. 3º - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.

¹⁴ A esse respeito, a SIN cita o voto proferido pelo Diretor Eli Loria, no âmbito do PAS CVM nº RJ2008/10181, julgado em 31/3/2009.

¹⁵ Parecer nº 00008/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 175/176).

¹⁶ Foram enviados ofícios para os endereços constantes da base de dados do SERPRO, bem como para os os endereços constantes do cadastro (cancelado) dos agentes autônomos de investimentos junto à CVM. Todavia, em ambos os casos, os ofícios forma devolvidos pelos Correios (fls. 179/198 e 204/206).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/1034

Acusados: TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
Marco Aurélio Carvalho Côrtes

Assunto: Atuação irregular como administrador de carteira de valores mobiliários (infração ao artigo 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999, ao artigo 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e ao artigo 16, inciso VI, alínea “b” da Instrução CVM nº 434, de 2006).

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1. Cuida-se de acusação formulada contra TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (“**TDS AAI**”) e Marco Aurélio Carvalho Côrtes (“**Marco Aurélio**”) por atuarem como administradores de carteira de valores mobiliários sem o competente registro na CVM, em desacordo com o art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999, o art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e o art. 16, inciso VI, alínea “b” da Instrução CVM nº 434, de 2006.

2. À época dos fatos, a administração de carteiras de valores mobiliários era regulada pela Instrução CVM nº 306, de 1999, que no seu art. 3º estabelecia que *“a administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM”*.

3. A Instrução CVM nº 558, de 2015, que substituiu o normativo anteriormente citado, manteve a mesma obrigatoriedade de autorização pela CVM, ao estabelecer no art. 2º que *“a administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM”*.

4. As regras estabelecidas pela CVM decorrem do que preceitua a Lei nº 6.385, de 1976, no art. 23, que ao tratar do tema diz: *“o exercício profissional da administração de carteira de valores mobiliários de outras pessoas está sujeita à autorização prévia da Comissão [ao se referir à CVM]”*.

5. Além disso, a administração irregular de carteira de valores mobiliários é expressamente vedada a agentes autônomos de investimento registrados junto à CVM, seja pela norma vigente à época (art. 16, inciso IV, “b”, da Instrução CVM nº 434, de 2006)¹, seja pela norma atual (art. 13, inciso IV, da Instrução CVM nº 497, de 2011)².

6. No caso concreto, a atuação da TDS AAI e de Marco Aurélio se assemelha a de tantos outros que já foram punidos pela CVM por atuarem irregularmente como administradores de carteira de valores mobiliários sem o competente registro, como ficará demonstrado no transcorrer deste voto³.

7. O conjunto de provas que me convencem da atuação irregular dos Acusados tem seu marco inicial nos e-mails por meio dos quais M.A.C. e F.H.L.C. forneceram a Marco Aurélio o *login* e a senha de acesso às suas respectivas contas junto ao sistema de *home broker* da corretora, no intuito de que seus recursos fossem geridos pelos Acusados (fls. 30/33 e 36/37). A meu ver, tais emails evidenciam uma relação entre, de um lado, alguém que se apresentava como um profissional habilitado a atuar no mercado, e que vendia serviços de administração de recursos, e de outro, pessoas que se utilizariam desses serviços.

8. Aliás, em suas reclamações, os investidores ressaltaram que Marco Aurélio era pessoa conhecida no Estado de Mato Grosso como "Assessor Financeiro", com especialidade em renda variável, reconhecimento decorrente da promoção de cursos sobre o mercado de ações na Capital do Estado e no Interior. Também no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/10874, julgado em 28/4/2009, o Diretor Relator, Otávio Yazbek, destacou em seu voto a mesma forma de atuar de Marco Aurélio, ao dispor que:

1. No presente caso, TDS⁴ e seu sócio Marco Aurélio, são acusados do exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM. Conforme apurado pela SIN, os Acusados estariam promovendo, na região Centro-Oeste do país, cursos livres com o objetivo de habilitar indivíduos a realizar investimentos no mercado de capitais. Pelo que se pode depreender do Termo de Acusação, parte dos alunos destes cursos, frequentados principalmente por pessoas físicas sem experiência de investimento em valores mobiliários, contrataria também os serviços de administração de carteira prestados pelos Acusados. O processo teve início a partir de denúncias formuladas por dois investidores através do sítio eletrônico da CVM.

9. As primeiras mensagens, trocadas em agosto de 2009, não deixam dúvidas de que M.A.C. e F.H.L.C. confiaram a TDS AAI e a Marco Aurélio a administração de seus recursos, por meio do livre acesso à suas contas junto à S. Corretora, para as quais transferiram parte de suas economias. Cito, por exemplo, as mensagens datadas de 27 e 28/8/2009 (fl. 36):

De: [M.A.C.]

Para: Marco Aurélio – TDS Investimentos

Olhei minha carteira e vi que vc já mexeu. Pode me indicar o que foi feito?

De: Marco Aurélio – TDS Investimentos

Para: [M.A.C.]

vendemos csna3 para recomprar mais abaixo e compramos valei32, para vender hoje na abertura, se abrir subindo um pouco... preciso esperar o mercado se definir (se volta a subir ou cai mesmo), para adotarmos o ponto certo de entrar com o dinheiro todo.

De: [M.A.C.]

Para: Marco Aurélio – TDS Investimentos

Boa Tarde marco.

Estou indo ao banco para transferir mais 33.500,00 – boas compras.

Na segunda feira estou mandando o dinheiro da [F.H.L.C.], inclusive estou te repassando o e-mail da [S. corretora] em relação a conta dela.

10. De fato, as notas de corretagem acostadas às fls. 100 a 120 demonstram que, a partir de agosto de 2009, foram realizadas operações em nome dos investidores junto aos mercados à vista, de opções e a termo da Bolsa.

11. A meu ver, as diversas mensagens trocadas entre os Acusados e os investidores, anexadas aos presentes autos, formam um claro painel de como era conduzida a administração dos recursos e de como os investidores foram induzidos e mantidos em erro, a partir de informações incompletas sobre os acontecimentos.

12. É o que comprovam os e-mails, enviados aos investidores pela TDS AAI e por Marco Aurélio entre setembro de 2009 e março de 2010, contendo relatórios mensais acerca dos investimentos realizados em suas contas, que apontavam em sua maioria para a realização de ganhos no período (fls. 38/87). A título de exemplo, vale transcrever email enviado por Marco Aurélio em 07/1/2010 (fl. 73):

*De: Marco Aurélio – TDS Investimentos
Para: [M.A.C.]*

Boa Tarde M.A.C.

Segue em anexo o fechamento de Dezembro. As expectativas para o ano são cada dia maiores, porém tudo indica que teremos uma pequena queda nas próximas semanas, já que o mercado subiu muito. Para nós seria ótimo uma eventual queda para podermos recomprar as opções que vendemos e que está nos atrapalhando bastante, mas com calma, tudo se ajeita.

Estamos em processo de reestruturação e organização aqui na empresa, que passa pela mudança da sede, aumento de pessoal e, inclusive, mudança de corretora, além do formato de trabalho. Em breve, entrarei em contato por telefone para explicar como isso se dará e as vantagens deste novo formato.

Outro detalhe importante é que a partir do próximo mês o fechamento mensal será enviado pelo [E.B.O.], sócio e financeiro aqui da empresa (...). Desta forma esperamos conseguir enviar os relatórios com mais rapidez.

13. Além disso, infere-se do teor da reclamação e dos emails anexos aos autos que Marco Aurélio, ao ser diretamente questionado por M.A.C. e F.H.L.C. acerca de seus investimentos, teria omitido que as posições BTC, que constavam como crédito, eram, de fato empréstimos, ludibriando, conscientemente, os investidores (fls. 88/94 e 98/99)⁵.

14. É incontroverso também o caráter profissional da atividade desempenhada pelos Acusados, diante do pagamento de remuneração mensal, por investidor, no valor de R\$500,00, caso houvesse lucro superior a R\$ 1.000,00 no período. Prova disso é que, juntamente com os relatórios mensais, eram encaminhados aos investidores, por email, os respectivos boletos de pagamento. Comprova ainda a existência de remuneração o e-mail datado de 23/9/2009, no qual M.A.C. afirma a Marco Aurélio que "Gostaria de agendar com vc mensalmente a baixa do valor de R\$500,00 da minha conta e da conta da [F.H.L.C.] para pagamento de seus honorários" (fl. 45).

15. A meu sentir, são fartas e incontestáveis as provas de que a TDS AAI e Marco Aurélio atuaram irregularmente como administrador de carteiras de valores

mobiliários, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999, ao art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e ao art. 16, inciso VI, alínea "b" da Instrução CVM nº 434/2006.

16. Nesse tocante, ainda que não se possa recorrer no caso concreto ao instituto da reincidência, para fins da aplicação de penalidade nos termos do disposto no art. 11, §2º, da Lei 6.385/76⁶, não se pode ignorar o histórico de Marco Aurélio que, mesmo ciente de sua condenação pela CVM, em abril de 2009, justamente pela atuação irregular como administrador de carteiras de valores mobiliários⁷, permaneceu angariando investidores no intuito de administrar seus recursos, como ocorreu em relação a M.A.C. e F.H.L.C., em agosto do mesmo ano.

17. Especificamente quanto à TDS AAI, não tenho dúvidas que também lhe cabe responsabilidade pelo ilícito de que se cuida. Afinal, a sociedade de agentes autônomos foi, a meu sentir, essencial para conceder a roupagem necessária à atividade irregular de administração de carteira, concedendo-lhe o caráter profissional exigido para esse tipo de atividade. Os diversos emails trocados com os investidores evidenciam que Marco Aurélio, sócio majoritário da TDS AAI, apresentava-se como "Diretor Comercial" do que denominava "Grupo TDS", com endereço em seis capitais do país⁸. Mais que isso, o nome "TDS", juntamente com "Ortiz Agente Autônomo de Investimentos Ltda.", expressamente constava dos boletos enviados aos investidores para fins da remuneração pelos serviços prestados.

18. A atuação da TDS AAI, inclusive, é reforçada pelo próprio Marco Aurélio ao informar aos investidores, no email de janeiro de 2010, transcrito no item 12 acima, que a sociedade estaria em processo de reestruturação e organização, incluindo mudança da sede, aumento de pessoal e troca de corretora, e que esse "novo formato de trabalho" lhes traria vantagens.

19. Aliás, a atuação conjunta da pessoa física e da pessoa jurídica na administração irregular de carteira de valores mobiliários é verificada em diversos precedentes da CVM, sempre no intuito de transmitir uma imagem mais convincente de profissionalismo junto aos investidores que se busca captar⁹.

20. Ora, a CVM, ao exigir prévia autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, certamente o fez com o objetivo de dar maior segurança ao investidor desejoso de entregar os seus recursos à administração de terceiros. Afinal, o investidor que abdica da possibilidade de gerir diretamente os seus recursos e opta por fazê-lo através de um profissional, é atraído por uma série de vantagens, dentre elas, inegavelmente, a qualificação daqueles que irão zelar pelos recursos investidos. Não por outra razão que as pessoas interessadas em se habilitar para exercer tal atividade necessitam preencher uma série de requisitos que comprovem sua aptidão, sem os quais a CVM não lhes concederá a autorização pleiteada.

21. Vale dizer, o sistema de credenciamento de pessoas aptas a administrar carteiras de valores mobiliários tem como pressuposto estrutural a proteção dos investidores, razão pela qual a burla ao credenciamento imposto pela CVM, para além de violar norma expressa, contida no art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, constitui grave infração à credibilidade e, por via de consequência, à própria higidez do mercado de valores mobiliários.

22. Assim, considerando tudo o que foi exposto, e a gravidade das irregularidades cometidas, voto:

- a) pela condenação da **TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda.** à penalidade de multa no valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do inciso II do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, por infração ao prescrito no art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999, art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e art. 16, inciso VI, alínea “b” da Instrução CVM nº 434, de 2006; e
- b) pela condenação de **Marco Aurélio Carvalho Côrtes** à penalidade de proibição temporária para o exercício do cargo de administrador de carteira de valores mobiliários, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do inciso VII do artigo 11 da Lei nº 6.385, de 1976, por infração ao prescrito no art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999, art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e art. 16, inciso VI, alínea “b” da Instrução CVM nº 434, de 2006.

23. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 27/2015, para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas competências.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ Art.16. É vedado ao agente autônomo de investimento:

(...)

IV – contratar com investidores a prestação de serviços de:

(...)

b) administração de carteira de títulos e valores mobiliários, salvo se o agente autônomo – pessoa natural, autorizado pela CVM também para exercer a atividade de administração de carteira, não estiver contratualmente vinculado, direta ou indiretamente, a entidades do sistema de distribuição de valores.

² Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º:

(...)

IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;

³ Processos Administrativos Sancionadores CVM nº RJ2009/10246, julgado em 09.11.2010; RJ2011/940, julgado em 10.7.2012; RJ2012/9490, julgado em 10.3.2015; RJ2012/12175, julgado em 02.6.2015, RJ2014/11558, julgado em 11.8.2015; RJ2014/8297, julgado em 08.9.2015, e SP2012/480, julgado em 06.10.2015.

⁴ Trata-se da TDS System Ltda., sociedade da qual Marco Aurélio era controlador, também acusada no citado PAS.

⁵ De acordo com os investidores, em reunião realizada em 28/05/2010, Marco Aurélio teria relatado “...de seu próprio punho que tínhamos os valores declinados nos ‘relatórios’ indicando que [M.A.C.] tinha o valor de R\$ 117.821,00 e [F.H.L.C.] tinha o valor de R\$ 73.061.00” (fls. 93/94). Entretanto, M.A.C. e F.H.L.C. teriam posteriormente sido informados pela corretora que seu saldo verdadeiro era de R\$ 17.260,51 e R\$15.180,95, respectivamente (fls. 98/99).

⁶ “nos casos de reincidência serão aplicados, alternativamente, multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade prevista nos incisos III a VII do caput deste artigo”. Segundo voto do Diretor Pedro Marcílio (PAS CVM nº RJ2005/5936, julgado em 04.05.06), utilizando-se as regras de reincidência constantes do Código Penal, mais especificamente do art. 63, para que ocorra reincidência, os

fatos investigados devem ter ocorrido após o trânsito em julgado da primeira decisão, o que não ocorreu no caso concreto, já que o trânsito em julgado da decisão da CVM ocorreu apenas em junho de 2010.

⁷ Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/10874, julgado em 28/4/2009.

⁸ Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador (vide fl. 38).

⁹ Vide Processos Administrativos Sancionadores CVM nº RJ2009/10246, julgado em 09.11.2010; RJ2011/940, julgado em 10.7.2012; RJ2012/9490, julgado em 10.3.2015; RJ2012/12175, julgado em 02.6.2015, RJ2014/11558, julgado em 11.8.2015; RJ2014/8297, julgado em 08.9.2015, e SP2012/480, julgado em 06.10.2015.

¹ Art. 2º O agente autônomo de investimento é a pessoa natural que obtém registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para exercer, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a atividade de distribuição e mediação de valores mobiliários.

Parágrafo único. Os agentes autônomos de investimento podem constituir pessoa jurídica para o exercício da atividade referida no caput, observados os requisitos desta Instrução.

Manifestação de Voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na continuação da Sessão de Julgamento do PAS CVM nº RJ2015/1034, iniciada em 12 de julho de 2016 e suspensa naquela data devido ao seu pedido de vista dos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/1034

Declaração de Voto

1. Conforme já me manifestei no PAS CVM nº SP2012/374, julgado em 19/07/2016, entendo que o exercício da atividade de agente autônomo de investimento é praticado apenas por pessoas naturais cadastradas como tais na CVM, mesmo quando eles constituem de sociedade uniprofissional, a qual terá natureza meramente instrumental. Transcreve-se, por sua pertinência, o referido voto que analisou detalhadamente a questão:

58. *A Hera, sociedade de AAI, também foi acusada pelas mesmas infrações dos agentes autônomos que participavam do seu capital social.*

59. *A defendente alega que a pessoa jurídica seria somente uma ficção, e que ela própria não praticaria ato algum, pois seu propósito seria apenas proporcionar ao sócio agente autônomo de investimento estrutura para o exercício de sua atividade profissional.*

60. *Acrescenta que ela não teria emitido, repassado ou acatado ordens, pois não teria "vontade própria, não [teria] raciocínio, e nem cognição, para, por si só, se dar às práticas ora imputadas a seus sócios". Conclui, então, com base nos artigos 2º, 3º e 17 da ICVM 434/06¹, que apenas o AAI pessoa física poderia ser responsabilizado, uma vez que ele seria, como o nome já diz, "autônomo", tornando-se impossível monitorar e fiscalizar toda sua atividade diária.*

61. *Trata-se de questão polêmica² e de difícil análise, o que é agravado pelo conteúdo pouco preciso da ICVM 434/06, vigente à época dos fatos e que foi revogada em 2011 pela ICVM 497, que aprimorou intensamente o regime regulatório aplicável aos agentes autônomos de investimento.*

62. *A ICVM 434/06, embora de forma um tanto reticente e por vezes contraditória, previa que a autorização para o exercício de atividade de agente*

autônomo de investimento "somente ser[ria] concedida à pessoa natural" (art. 3º, g.n), o que estava em sintonia com o art. 2º, que consignava que AAI seria "preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários".

63. Além disso, o art. 17³ da ICVM 434/06, ao abordar a responsabilidade pelo exercício da atividade em questão, afirmava categoricamente que o AAI "é responsável (...) pelos atos que infringirem normas legais ou regulamentares", o que denotaria que apenas o agente autônomo propriamente, enquanto pessoa física que exerce a atividade, poderia ser responsabilizado.

64. O parágrafo único do art. 2º da ICVM 434/06, por sua vez, permitia que os agentes autônomos de investimento constituíssem pessoa jurídica, a qual obrigatoriamente teria como sócios unicamente⁴ agentes autônomos de investimento pessoas naturais, que, com exclusividade, exerceriam as atividades próprias de agente autônomo (art. 8º, II⁵).

65. Como se verifica, a ICVM 434 já indicava, nada obstante suas limitações e incongruências⁶, que, mesmo no caso de participação em uma sociedade, a atividade própria de agente autônomo era exercida pelas pessoas naturais que compunham o quadro social, de forma que a sociedade teria natureza meramente instrumental, servindo apenas para fornecer uma estrutura que colaborasse com a atuação dos profissionais (pessoas naturais) autorizados pela CVM.

66. Trata-se, pelas suas características, de sociedade com caráter "uniprofissional", em que todos os sócios possuem a mesma profissão e utilizam a pessoa jurídica apenas como instrumento que fornece a estrutura física e formal para que cada um dos sócios exerça suas atividades profissionais de forma pessoal e recebam remuneração em virtude de seu trabalho, deduzidas as despesas da pessoa jurídica ou conforme algum outro critério de distribuição previsto no contrato social⁷.

67. Um exemplo emblemático dessa situação seria a sociedade de advogados, em relação à qual a Lei nº 8.906/94 adotou sistema no qual o exercício da atividade profissional de advogado é sempre pessoal, mesmo quando ele estiver vinculado a uma pessoa jurídica (necessariamente uniprofissional).

68. O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, editado com fulcro no artigos 15 e 78 da Lei nº 8.906/94, é explícito ao afirmar que as "atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos" (redação atual conforme Resolução OAB nº 02, de 12/04/2016)⁸.

69. A semelhança do sistema legal das sociedades de advogados com o adotado pelas instruções editadas pela CVM sobre AAI (ICVM nºs. 434/11 e 497/11), apresenta-se bastante evidente, o que corrobora que a sociedade de agentes autônomos de investimento é apenas uma estrutura para facilitar o exercício pessoal da profissão de AAI. A título de exemplo dessas semelhanças, podemos citar a natureza simples das sociedades, a proibição de sócios que não sejam profissionais habilitados para o exercício da profissão e a impossibilidade de participação em de mais de uma sociedade do gênero.

70. Aliás, a norma mais recente (ICVM 497/11), editada após os fatos analisados no presente caso, deixa todas essas questões muito mais claras, reiterando, de forma bem técnica e precisa, que o AAI é apenas a pessoa natural (artigos 1º e 3º), bem como que o quadro societário da pessoa jurídica, de

natureza simples, deve ser composto exclusivamente por Agentes Autônomos de Investimento, sem exceção.

71. *Além disso, ao prever a obrigação de a corretora manter lista atualizada dos AAI a ela vinculados, a ICVM 497/11 determina que tal lista deve conter as pessoas naturais habilitadas pela CVM (art. 16, § 2º), e não a pessoa jurídica, justamente porque esta não exerce a atividade de agente autônomo.*

72. *O AAI, segundo a regra atual, para exercer sua atividade, deve celebrar contrato com corretora⁹ ou ser sócio de pessoa jurídica (sociedade de AAI) que tenha contrato com corretora, de forma que se encontra, atualmente, bastante claro que a pessoa jurídica seria apenas uma "ponte" formal entre a corretora e o AAI sócio.*

73. *Nesse contexto, que buscou propósitos de racionalização, a corretora, desde que celebre contrato com a sociedade de AAI, passaria a poder operar com todos os sócios (AAI) desta pessoa jurídica, sem a necessidade de um contrato individual para cada profissional (art. 3º e incisos da ICVM 497/11).*

74. *Apesar de, à época dos fatos, vigorar a ICVM 434, a análise da nova ICVM 497 ajuda a entender a natureza e o objetivo da sociedade de AAI, uma vez que foi editada para aperfeiçoar e esclarecer o sistema regulatório pertinente.*

75. *Aliás, interessante ressaltar que o relatório de análise da audiência pública relativa à ICVM 497 contém trecho que aduz expressamente ter a nova regulação optado por "manter" a regra de que o responsável pela atividade é a pessoa natural habilitada como AAI, além da corretora a quem este estiver vinculado, pelo dever de fiscalização. Eis o trecho pertinente do aludido relatório (item 3.2):*

"Neste sentido, será mantida a linha originariamente adotada, de permissão de constituição de pessoas jurídicas e de exigência de seu registro, sem que persista, porém, a distinção entre agente autônomo pessoa natural e agente autônomo pessoa jurídica, hoje adotada. As responsabilidades permanecem, assim, nas pessoas naturais prestadoras dos serviços e, como se verá em outros pontos, nos intermediários." (g.n.)

76. *Não há, portanto, dúvida de que, mesmo antes da ICVM 497/11, seria o AAI (pessoa natural) responsável pelos atos que realizar no exercício de sua atividade, sem previsão de solidariedade, corresponsabilidade ou dever de fiscalização pela sociedade uniprofissional da qual participe.*

77. *A corretora, por sua vez, teria a obrigação de fiscalização/supervisão dos agentes autônomos (pessoas naturais) a ela vinculados, conforme previa o art. 17, § 2º, da ICVM 434/06 (regra que, atualmente, encontra-se no art. 17 e seus incisos da ICVM 497/11). A regulação da CVM poderia incluir regra semelhante para as sociedades de agentes autônomos, mas assim não o fez, o que impede que se considere essa sociedade como um "gatekeeper" adicional no sistema¹⁰.*

78. *Além disso, a acusação não imputou qualquer ato, omissivo ou comissivo, à pessoa jurídica Hera, apenas afirmando que seus sócios agentes autônomos teriam agido de forma irregular e disso decorreria sua responsabilidade, o que não me parece adequado, uma vez que não seria cabível a responsabilização objetiva em sede disciplinar, em virtude da conduta de outra pessoa e sem que se demonstrasse a coparticipação¹¹.*

79. *Não se deve, contudo, confundir essa situação com aquela em que o ato é da sociedade, mas que o diretor que a "representou" (rectius, "presentou") ou*

*responsável técnico podem ser punidos em virtude da violação dos seus deveres (fiduciários ou de outra natureza), hipóteses em que haveria duas condutas sujeitas a punição (ato em si e violação do dever fiduciário ou técnico). No presente caso, repise-se, os atos **não** são da sociedade, mas sim do AAI pessoa física, inexistindo ainda qualquer obrigação legal ou regulatória de fiscalização por parte da sociedade uniprofissional, e nem mesmo previsão de regras sobre centros de imputação de responsabilidade.*

80. *Assim, diante das características da sociedade em questão, da regulação aplicável e do sistema pertinente aos agentes autônomos de investimento, não se poderia admitir, especialmente em face da ausência de regra específica, que o ato pessoal do AAI acarretasse a responsabilidade da sociedade instrumental que lhe dá suporte, posto que se configuraria uma espécie de responsabilidade disciplinar objetiva.*

81. *Como já exposto, as normas da ICVM 434/06 (arts. 2º e 3º), bem como as regras ainda mais claras da nova ICVM 497/11 (arts. 1º e 3º), demonstram que a atividade de agente autônomo é exercida apenas pela pessoa física registrada como tal na CVM, sendo a sociedade de AAI meramente um suporte estrutural e "ponte" com a corretora (art. 3º, II, da ICVM 497/11 – dispensando contratos individuais), razão pela qual não tenho dúvida de que a conduta é pessoal do agente autônomo pessoa física, não podendo a sociedade ser punida de forma objetiva, sem que mesmo lhe seja imputada uma conduta "típica" específica.*

82. *Registre-se, para que o presente voto não seja interpretado de forma equivocada, que o entendimento exposto não repercute na questão geral da possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa jurídica (como alguns advogam), mas apenas que, no caso de agente autônomo de investimento, por opção regulatória, adotou-se um modelo em que a pessoa natural é registrada e fica habilitada a realizar essa atividade, sendo a sociedade apenas um instrumento jurídico que oferece estrutura e outras vantagens formais para que os agentes autônomos individualmente atuem.*

83. *Saliente-se que a sociedade de AAI, enquanto pessoa jurídica, não está habilitada a mandar ordens para a corretora executar, porquanto essa atividade fica restrita a seus sócios (todos AAI), o que torna evidente que ela não exerce a função de agente autônomo de investimento, e, portanto, até mesmo por ausência de conduta, estaria inviabilizada a sua punição pelo exercício dos atos irregulares em questão.*

84. *Se o regime regulatório permitisse que a sociedade fosse habilitada como agente autônomo, e exercesse a atividade pertinente por meio de seus funcionários ou diretores, não haveria dúvida quanto à possibilidade de sua punição disciplinar, pois o ato seria seu. Não é essa, contudo, a modelagem regulatória em análise, e nem mesmo seria a realidade de fato existente no mercado.*

85. *Além disso, nenhuma norma regulatória prevê que a sociedade seria responsável pelos atos dos agentes autônomos, o que configura mais uma razão a impedir que se replique a punição do profissional autônomo na pessoa jurídica uniprofissional da qual ele participa.*

86. *Ressalve-se que existem hipóteses que envolvem atos próprios da sociedade de AAI, o que, naturalmente, justifica sua punição, como no caso de ela admitir em seu quadro societário alguém que não seja agente autônomo de investimento, ou quando preste, enquanto pessoa jurídica, informação falsa ao investidor, hipóteses em que seria cabível e necessária sua punição (como*

exemplo, podemos citar o PAS CVM nº SP2013/0292, julgado nesta mesma sessão, no qual a Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. foi condenada por atos próprios).

87. *Quanto ao argumento de que a sociedade obteve benefícios financeiros em decorrência das operações irregulares praticadas pelos AAI pessoas físicas, cumpre ressaltar que o que se está aqui analisando é a responsabilidade disciplinar, o que não se confunde com a responsabilidade civil, razão pela qual o recebimento de benefício, por si só, não justifica a punição disciplinar, para a qual seria necessário ato violador de algum dispositivo legal ou regulatório.*

88. *Desta forma, a sociedade poderá, eventualmente, ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos causados aos usuários do serviço, com base em normas de direito civil, mas isso não justifica nem repercute na questão da responsabilidade administrativa¹².*

89. *Nesse contexto, não vejo como condenar a sociedade pelos atos pessoais do agente autônomo que dela é sócio, pelas seguintes razões que são aqui sintetizadas: a) conforme regulamento da CVM, a pessoa habilitada a atuar como AAI é apenas a pessoa física registrada como tal; b) os atos irregulares em discussão foram realizados pelos agentes autônomos pessoas físicas; c) a sociedade uniprofissional de AAI possui natureza apenas auxiliar e instrumental, não podendo atuar diretamente como AAI; d) não houve ato ou omissão da sociedade que acarrete infração a alguma norma legal ou regulatória; e e) não há responsabilidade objetiva em sede disciplinar.*

90. *Do exposto, voto pela ilegitimidade da Hera quanto à acusação de atuar irregularmente como administrador de carteira de valores mobiliários (art. 23 da Lei 6.385/76, c/c o art. 3º da ICVM 306/99, e ao art. 16, inciso IV, "b", da ICVM 434/06), uma vez que os atos que suportam a acusação não foram por ela realizados".*

2. Anote-se que, no presente caso, a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN acusou a sociedade TDS de exercício de atividade de administração irregular de carteira ("*responsabilização da TDS ... por infringência ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385, de 07/12/1976, no artigo 3º da Instrução CVM nº 306, de 5/05/1999, e no art. 16, inciso IV, 'b', da Instrução CVM nº 434, de 22/06/2006*"), mas não indicou nenhum ato da TDS (pessoa jurídica) que configure o exercício de atividade de administração de carteira, tanto que todos os atos em análise no processo foram realizados por Marco Aurélio Carvalho Côrtes, este sim, inequivocamente, autor das infrações destacadas na acusação.

3. Desta forma, em linha com os argumentos expostos no precedente acima transcrito, que ressalta a impossibilidade sistêmica de que ordens para a corretora sejam enviadas pela sociedade de agentes autônomos (pessoa jurídica), bem como a ausência de indicação/comprovação pela acusação de conduta pessoal da TDS que configure administração irregular, considero que a acusação equivocou-se nesse ponto específico.

4. Esclareça-se que a sociedade de AII poderá ser punida quando comete infrações próprias (v.g., PAS SP 2013/0292), mas, em regra, não terá responsabilidade pelas infrações cometidas pelo AII que seja seu sócio, como ocorre no presente caso, em que a acusação foi de exercício irregular da atividade de agente autônomo, atividade esta que, pelo próprio sistema adotado, é exercida pessoalmente pelos agentes autônomos de investimento (pessoas físicas), mesmo no caso de eles participarem de sociedade uniprofissional.

5. O autor dos ilícitos, portanto, foi Marco Aurélio Carvalho Côrtes (AAI sócio majoritário da TDS), o qual deve ser punido pelas irregularidades cometidas, como bem analisado pelo Diretor-Relator, devendo ser considerado, ainda, na dosimetria da pena, a caracterização da infração como grave, na forma do art. 18 da ICVM 306/99¹³, bem como a nocividade e premeditação da conduta do acusado, que, conforme comprovado, induziu investidores a abrirem contas em corretoras e lhe enviarem *login* e senha de acesso, permitindo, com isso, a administração irregular de recursos (fls. 30-33 e 36-37).

6. Do exposto, voto pela condenação de Marco Aurélio Carvalho Côrtes à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 6 (seis) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, na forma do inciso VII do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, por agir irregularmente como administrador de carteira de valores mobiliários (art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, art. 23 da Lei nº 6.385/76, e art. 16, inciso VI, alínea "b", da Instrução CVM nº 434/06), e, em relação à acusação contra TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda., voto pela extinção da ação, em linha com a argumentação já apresentada no PAS CVM nº SP2012/374, julgado em 19/07/2016 (acima transcrito).

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor

¹ Art. 2º O agente autônomo de investimento é a pessoa natural que obtém registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para exercer, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a atividade de distribuição e mediação de valores mobiliários.

Parágrafo único. Os agentes autônomos de investimento podem constituir pessoa jurídica para o exercício da atividade referida no caput, observados os requisitos desta Instrução.

² Os julgamentos já proferidos pelo colegiado são no sentido da responsabilização da sociedade em decorrência dos atos dos seus sócios agentes autônomos de investimento (PAS SP2012/480) posição da qual divirjo, pelos motivos que serão expostos no presente voto.

³ Art. 17. O agente autônomo de investimento é responsável, civil e administrativamente, no exercício de suas atividades, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos atos que infringirem normas legais ou regulamentares, sem prejuízo de sua eventual responsabilidade penal.

§1º A instituição intermediária é responsável pelos atos praticados pelo agente autônomo na condição de seu preposto.

§2º A responsabilidade administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de supervisão sobre os atos praticados pelo agente autônomo.

⁴ O § 1º do art. 8º permitia sócios com pequena participação (2% no capital social e nos lucros) que não fossem AAI, mas eles não poderiam exercer atividades pertinentes à área de atuação própria dos agentes autônomos.

⁵ Art. 8º A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: (...)

II – tenha como sócios unicamente agentes autônomos autorizados pela CVM, e a eles seja atribuído, com exclusividade, o exercício das atividades

referidas no art. 2º, sendo todos os sócios responsáveis perante a CVM pelas atividades da sociedade.

6 Como exemplo dessas incongruências e imperfeições constantes da ICVM 434/06, pode-se citar o conteúdo do *caput* do art. 8º que fala em autorização concedida pela pessoa jurídica, ou mesmo o capítulo que começa no art. 8º, cujo título é "Autorização do Agente Autônomo - Pessoa Jurídica"

⁷ No caso da Hera, 60% dos recursos obtidos com o serviço eram distribuídos aos AAI na proporção das corretagens geradas por seus clientes.

⁸ Isso não impede que exista responsabilização civil da sociedade pelos danos causados, mas a responsabilidade disciplinar seria apenas do profissional que infringe regra específica.

⁹ Ou, para ser mais preciso, com "*instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários*".

¹⁰ Nada impediria, e até seria, a meu sentir, salutar, que a norma regulatória prevísse que a sociedade teria obrigação de fiscalizar e adotar procedimentos para evitar que os AAI que participem de seu capital atuassem de forma irregular. Nesse caso, a sociedade seria responsável por condutas ou omissões próprias, o que justificaria a punição de forma independente e legítima.

¹¹ Reitere-se que a sociedade de AAI não exerce atividade própria de agente autônomo, mas apenas fornece estrutura material e formal para que as pessoas físicas exerçam pessoalmente as atividades profissionais para as quais oram habilitados na CVM.

¹² Aliás, a mesma situação ocorre em relação à sociedade de advogados, em relação à qual, apesar da natureza pessoal da atividade, a própria Lei 8906/94 previu, em sua art. 17, a responsabilidade civil concorrente entre os advogados e a sociedade.

¹³ Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos artigos 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na segunda continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/1034, iniciada em 12 de julho de 2016, suspensão naquela data devido ao pedido de vista dos autos feito pelo Diretor Gustavo Borba, retomada em 02 de agosto de 2016 e novamente suspensão, em razão do pedido de vista dos autos feito pelo Diretor Pablo Renteria.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/1034

Declaração de Voto

1. Senhor Presidente, não restam dúvidas, no presente caso, acerca da ocorrência da administração irregular de carteira de valores mobiliários, por quem não tinha a devida autorização da CVM para o exercício da atividade, em infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976, e no art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999 (vigente à época dos fatos).

2. Também não se controverte a responsabilidade do acusado Marco Aurélio Carvalho Côrtes pela aludida infração, tendo em vista as fartas evidências acostadas aos autos.

3. O que se discute, a partir da divergência inaugurada pelo Diretor Gustavo Borba, é, precisamente, a responsabilização da sociedade TDS – Agente Autônomo de

Investimentos Ltda. O voto proferido pelo Diretor traz oportunamente à tona discussão relativa ao cabimento de responsabilidade, na esfera administrativa, da pessoa jurídica. Talvez porque a CVM tenha firmado há tempo sua posição na matéria, pode parecer que se trate de questão plenamente sedimentada, que já não merecesse ser revisitada.

4. Entendo, ao reverso, cuidar-se de tema atualíssimo e de inegável relevância, vez que a grande maioria das atividades conduzidas nesse mercado é prestada por pessoas jurídicas. Em razão desse contexto, a discussão sobre as hipóteses de responsabilização, na esfera administrativa, da pessoa jurídica confunde-se, em larga medida, com os próprios limites da atuação sancionadora da CVM, assumindo, assim, uma dimensão transversal para a regulação do mercado de valores mobiliários.

5. Por isso que considero salutar a oportunidade dada pelo julgamento deste processo para avaliar, ainda que de maneira pontual, observados os estritos limites do caso concreto, uma premissa relevante que vem pautando o regime sancionador desta autarquia.

6. Nesse tocante, um dos pontos mais importantes – e que se faz presente no caso em apreço – consiste na identificação das razões que justificam a imputação de responsabilidade (administrativa) não apenas à pessoa natural que concorreu para a prática ilícita, mas também à sociedade que com aquela mantenha vínculos estatutários, societários ou contratuais. Em outras palavras, cuida-se de definir as condições sob as quais as consequências de determinado ilícito devem repercutir na esfera jurídica da pessoa jurídica.

7. Não me parece possível enfrentar tal questão em termos abstratos, procurando extrair uma regra única para a solução de todos os casos, dada a extrema variedade de circunstâncias em que pode ser suscitada a responsabilidade administrativa da pessoa jurídica. Nada obstante, duas reflexões de ordem geral se mostram particularmente valiosas.

8. A primeira é que, a meu ver, a discussão em torno dos critérios de imputabilidade de responsabilidade à pessoa jurídica deve ser pautada não apenas pelos seus aspectos jurídicos, mas também pelos seus aspectos regulatórios. Significa dizer que a aplicação, em determinado caso, de penalidade à pessoa jurídica deve ser avaliada tendo em conta as consequências daí decorrentes para o bom funcionamento do mercado de valores mobiliários, em particular os incentivos que desse modo são criados para os seus participantes. Afinal, sendo a pena instrumento a serviço da sociedade, voltado à tutela de variados bens jurídicos relevantes para a coletividade, parece apropriado manejá-la levando em consideração as finalidades que com ela se pretende alcançar. Cuidando-se da CVM, os bens jurídicos a serem protegidos são aqueles estabelecidos no art. 4º da Lei nº 6.385, de 1976.

9. Nessa direção, invoca-se usualmente a necessidade de “internalização” dos custos do ilícito para justificar o apenamento da pessoa jurídica. De fato, sendo a pessoa jurídica sociedade empresária, voltada à realização de lucro, a aplicação de multas pecuniárias ou de sanções restritivas de direitos que afetem a sua capacidade de gerar riqueza constitui poderoso mecanismo de dissuasão da prática ilícita, que não se alcançaria, com a mesma efetividade, se fossem punidas apenas as pessoas naturais envolvidas.

10. Acredito, contudo, que esse raciocínio tenha limites e não descarto *a priori* a possibilidade de o apenamento da sociedade ter consequências adversas, que vão à contramão daquilo que se busca na regulação do mercado de valores mobiliários. Por isso que me parece importante a CVM continuar, atentamente, a avaliar a eficiência do regime sancionador a que se submetem as pessoas jurídicas que participam do mercado.

11. A segunda reflexão de cunho geral que me parece relevante diz respeito aos elementos jurídicos de configuração do ilícito administrativo. Nesse ponto, parece-me importante evitar a perspectiva antropomórfica que concebe a responsabilidade administrativa da pessoa jurídica nos mesmos moldes da pessoa natural, deixando, assim, de reconhecer as especificidades inerentes àquela.

12. Afinal, como se sabe, a pessoa jurídica não é dotada de capacidade intelectual ou física própria. A sua ação ou omissão manifesta-se, necessariamente, por meio da conduta de uma ou várias pessoas naturais que com ela guardam algum vínculo contratual, estatutário ou societário. Desse modo, a pessoa jurídica responde administrativamente por ato que, no plano dos fatos, não é seu nem poderia sê-lo, mas que, juridicamente, lhe é imputável. Dessa diversa configuração do agir da pessoa jurídica decorrem importantes consequências para a configuração do ilícito administrativo, notadamente em matéria de culpabilidade, que devem ser levadas em devida consideração, sob pena de serem criadas distorções capazes de comprometer a atuação sancionadora da CVM.

13. Enfim, feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a responsabilidade da TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. pela atuação irregular como administrador irregular de carteira de valores mobiliários.

14. Concorde com o Diretor Gustavo Borba que, nos termos da regulamentação da CVM, a atividade de intermediação é exercida pessoalmente pelo agente autônomo de investimentos, tendo a respectiva sociedade índole uniprofissional, destinada a servir de suporte para a atuação de seus sócios. Por conseguinte, também concordo que recai exclusivamente sobre o agente pessoa natural a responsabilidade por eventuais irregularidades verificadas na prática de atos inerentes ao seu ofício, que consiste, precisamente, nos termos do art. 1º da Instrução CVM nº 497, de 2011, na:

“I - prospecção e captação de clientes;

II - recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e

III - prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.

Parágrafo único. A prestação de informações a que se refere o inciso III inclui as atividades de suporte e orientação inerentes à relação comercial com os clientes, observado o disposto no art. 10.”

15. No entanto, entendo que a situação enfrentada neste processo é diversa. O que se verifica, a partir do exposto nos parágrafos 17 a 19 do voto do Diretor-Relator, é que a TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. foi desvirtuada. Afastou-se de seu objeto social, tornando-se uma gestora de recursos irregular, que desempenhava atividade sem a autorização exigida pelo órgão regulador. A Instrução CVM nº 306, de 1999, do mesmo modo que a Instrução CVM nº 558, de 2015, que lhe sucedeu, era clara ao determinar, em seu artigo art. 3º, o prévio registro da administradora pessoa jurídica junto à CVM, nos seguintes termos: *"a administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM."*

16. Não tendo a TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. satisfeito a condição que lhe impunha a legislação, parece-me necessária a sua responsabilização. Não importa, a meu ver, o objeto social declarado, se a pessoa tem o escopo previsto no art. 2º da Instrução CVM nº 497, de 2011, ou qualquer outro. Em todo caso, a sociedade empresária que se presta à administração de valores mobiliários, sem a devida autorização, deve sujeitar-se às penalidades estabelecidas no art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, de modo a sofrer sanção capaz de desestimular a busca do lucro por meio de atividade exercida irregularmente.

17. Em suma, é por essa razão que me alinho à orientação que vem sendo adotada pelo Colegiado da CVM e acompanho o voto do Diretor-Relator.

18. A minha única divergência é em relação à penalidade aplicada ao acusado Marco Aurélio Carvalho Côrtes. Nesse ponto, acompanho o Diretor Gustavo Borba e voto pela condenação de Marco Aurélio Carvalho Côrtes à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 6 (seis) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, na forma do inciso VIII do artigo 11 da Lei nº 6.385, de 1976.

19. É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016

Pablo Renteria
Diretor

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/1034 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, na mesma linha da declaração de voto do Diretor Pablo Renteria, eu acompanho a penalidade proposta pelo Diretor-Relator no tocante à TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda., condenando-a ao pagamento de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00.

Quanto ao acusado Marco Aurélio Carvalho Côrtes, acompanho o voto do Diretor Gustavo Borba, que condenou o acusado à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de seis anos, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/1034 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

1. Assim como o Diretor Pablo Renteria, acompanho o voto do Diretor-Relator, divergindo, contudo, da penalidade proposta para o acusado Marco Aurélio Carvalho Côrtes.
2. Nesse ponto, também acompanho a pena sugerida pelo Diretor Gustavo Borba, votando pela condenação de Marco Aurélio Carvalho Côrtes à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de seis anos, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, na forma do inciso VIII do art. 11 da Lei nº 6.385/76.
3. Em minha visão, as características do caso demonstram a gravidade da conduta do acusado, que, não obstante a ausência dos devidos registros na CVM, propagou para diversos investidores a prestação de serviços de administração de carteira, induzindo-lhes a confiar as suas economias a ele.
4. Como muito bem exposto no voto condutor, é nítida a atuação irregular do acusado como administrador de carteiras, uma vez que, mesmo sem registro e já tendo sido condenado anteriormente pela mesma infração¹, o acusado se propôs a, mediante o pagamento de remuneração mensal, operar no mercado de valores mobiliários em nome dos investidores.
5. Para tanto, e como forma de ludibriá-los, o acusado fez uso de diversos artifícios, promovendo a sua atuação como assessor financeiro no Estado de Mato Grosso, inclusive por meio de pessoa jurídica, a TDS, que ajudava a conferir caráter profissional para perpetrar os ilícitos. Além disso, os investidores também foram induzidos e mantidos em erro por informações incompletas sobre seus investimentos, realçando a gravidade de sua conduta.
6. Em verdade, o cenário revela não apenas a inaptidão ou desconformidade de sua atuação com a atividade de administrador de carteiras, como também denota comportamento que em nada se coaduna com o que se espera de pessoa que se propõe a atuar no mercado de capitais como um todo.
7. A nocividade de condutas como a verificada no presente caso é altíssima, na medida em que os prejuízos causados aos investidores ludibriados contribui para afastá-los do mercado, prejudicando a confiança nos profissionais do setor e o próprio desenvolvimento do mercado de capitais.
8. Assim, acredito que a proibição temporária para o exercício de administrador de carteira de valores mobiliários, na forma do inciso VII do art. 11 da Lei nº 6.385/76, produziria poucos efeitos práticos, já que o acusado operava à

margem da regulação, sem possuir o adequado registro de que tratava a Instrução CVM nº 306/99, hoje revogada pela Instrução CVM nº 558/2015.

9. Por todo o exposto, creio que a penalidade prevista no inciso VIII do art. 11 da Lei nº 6.385/76, por afastar tais agentes do mercado de valores mobiliários, impedindo-lhes de atuar, direta, ou indiretamente, é a mais proporcional e apropriada á gravidade da conduta verificada.

10. É como voto.

Leonardo P. Gomes Pereira

PRESIDENTE

¹ PAS CVM nº RJ2008/10874, julgado em 28.04.2009.